

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
2787/2564

พนักงานอัยการจังหวัด  
นางสาว ค. กับพวก  
นาย ส.

โจทก์  
โจทก์ร่วม  
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 40, มาตรา 44/1, มาตรา 46

ป.วิ.พ. มาตรา 224 วรรคหนึ่ง

การยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตาม ป.วิ.อ. มาตรา 44/1 เป็นการใช้สิทธิยื่นคำร้องในคดีอาญาที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ มิใช่คดีที่ผู้เสียหายฟ้องเองโดยตรง จึงต้องถือว่าคำพิพากษาในส่วนที่เรียกค่าสินไหมทดแทนเป็นส่วนหนึ่งของคำพิพากษาในคดีส่วนอาญา ทั้งการพิพากษาคดีแพ่งที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญา ศาลจำต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีส่วนอาญาตาม ป.วิ.อ. มาตรา 46 ดังนั้น สิทธิในการอุทธรณ์ฎีกาเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนในคดีส่วนแพ่งต้องถือคดีส่วนอาญาเป็นหลัก หากคดีอาญาขึ้นมาสู่การพิจารณาของศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา คดีส่วนแพ่งก็ไม่ต้องห้ามอุทธรณ์หรือฎีกา

---

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 277,  
317

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณาสาวนางสาว ค. ผู้เสียหายที่ 1 และนาง ส. ผู้เสียหายที่ 2 ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต โดยให้เรียกผู้เสียหายที่ 1 ว่า โจทก์ร่วมที่ 1 และเรียกผู้เสียหายที่ 2 ว่า โจทก์ร่วมที่ 2

โจทก์ร่วมทั้งสองยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในคดีส่วนแบ่งแก่โจทก์ร่วมที่ 1 เป็นเงิน 100,000 บาท และแก่โจทก์ร่วมที่ 2 เป็นเงิน 80,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2548 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ร่วมทั้งสอง

จำเลยให้การในคดีส่วนแบ่งขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคสอง (เดิม) ประกอบมาตรา 80, 317 วรรคสาม (เดิม) การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานพรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเสียจากผู้ดูแลโดยปราศจากเหตุอันสมควรเพื่อการอนาจาร จำคุกกระทงละ 5 ปี รวม 2 กระทง จำคุก 10 ปี ฐานพยายามกระทำชำเราเด็กหญิงอายุยังไม่เกินสิบสามปี จำคุกกระทงละ 5 ปี 4 เดือน รวม 2 กระทง จำคุก 10 ปี 8 เดือน รวมจำคุก 20 ปี 8 เดือน กับให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ร่วมที่ 1 เป็นเงิน 60,000 บาท และชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ร่วมที่ 2 เป็นเงิน 20,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2548 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ค่าฤชาธรรมเนียมในคดีส่วนแบ่งให้เป็นพับ

โจทก์ร่วมที่ 2 และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษายืน

## จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่ฎีกาโต้เถียงกันฟังได้ว่า โจทก์ร่วมที่ 1 เกิดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2536 เป็นบุตรนาง น. กับนาย ม. ขณะเกิดเหตุโจทก์ร่วมที่ 1 อยู่ในการอุปการะเลี้ยงดูของโจทก์ร่วมที่ 2 โดยโจทก์ร่วมที่ 2 นำโจทก์ร่วมที่ 1 มาเลี้ยงดูตั้งแต่อายุ 1 เดือน จนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ช่วงเดือนมิถุนายน 2548 โจทก์ร่วมที่ 2 พาโจทก์ร่วมที่ 1 ไปพักอาศัยอยู่กับนาย ป. บุตรชาย โจทก์ร่วมที่ 2 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2548 โจทก์ร่วมที่ 2 พาโจทก์ร่วมที่ 1 ไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรว่าจำเลยกระทำชำเราโจทก์ร่วมที่ 1 ต่อมาวันที่ 29 สิงหาคม 2548 โจทก์ร่วมที่ 1 ไปตรวจร่างกายเพื่อหาร่องรอยการถูกกระทำชำเราที่โรงพยาบาล จากนั้นพนักงานสอบสวนจึงขอออกหมายจับจำเลย ต่อมาวันที่ 26 มีนาคม 2562 จึงจับจำเลยได้ ชั้นสอบสวนแจ้งข้อหาว่า กระทำชำเราเด็กหญิง อายุยังไม่เกินสิบสามปีซึ่งมิใช่ภริยาของตน พานुकคลอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเพื่อการอนาจาร และพรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครอง โดยปราศจากเหตุอันสมควรเพื่อการอนาจาร จำเลยให้การปฏิเสธ ชั้นสอบสวนโจทก์ร่วมที่ 1 และที่ 2 ให้การไว้ สำหรับความผิดฐานพรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเสียจากผู้ดูแล โดยปราศจากเหตุอันสมควรเพื่อการอนาจาร ศาลชั้นต้นลงโทษจำคุกจำเลยกระหนละ 5 ปี รวม 2 กระหน ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษายืน โดยยังคงลงโทษจำคุกจำเลยกระหนละไม่เกิน 5 ปี จำเลยฎีกาว่า พยานหลักฐานของโจทก์และโจทก์ร่วมทั้งสองฟังไม่ได้ว่าจำเลยกระทำความผิด อันเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐาน จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย ปัญหาดังกล่าวจึงยุติไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 7

คงมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า จำเลยกระทำความผิดฐานพยายามกระทำชำเราเด็กหญิงอายุยังไม่เกินสิบสามปีตามที่ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิจารณามาหรือไม่ เห็นว่า โจทก์ร่วมที่ 1 เบิกความถึงการกระทำของจำเลยในวันที่ 26 กรกฎาคม 2548 ว่า จำเลยได้ใช้อวัยวะเพศของจำเลยสอดใส่เข้าไปในอวัยวะเพศของโจทก์ร่วมที่ 1 แต่โจทก์ร่วมที่ 1 ร้องว่าเจ็บและเรียกให้คนช่วย แต่ไม่มีผู้ใดได้ยิน จำเลยจึงใช้อวัยวะเพศของจำเลยใส่ช่องปากของโจทก์ร่วมที่ 1 ประมาณ 5 นาที มีน้ำสีขาวไหลออกมาจากอวัยวะเพศของจำเลย ส่วนหนึ่งอยู่ในปากของโจทก์ร่วมที่ 1 บางส่วนไหลเลอะเสื้อผ้า และในวันที่ 25 สิงหาคม 2548 จำเลยใช้อวัยวะเพศของจำเลยถูกับอวัยวะเพศของโจทก์ร่วมที่ 1 ไปมา จากนั้นใช้อวัยวะเพศของจำเลยใส่เข้าไปในอวัยวะเพศของโจทก์ร่วมที่ 1 แต่ใส่ได้เพียงเล็กน้อย เนื่องจากโจทก์ร่วมที่ 1 เจ็บ จำเลยจึงใช้อวัยวะเพศของจำเลยใส่ช่องปากของโจทก์ร่วมที่ 1 จำเลยกดศีรษะโจทก์ร่วมที่ 1 ไว้ แล้วจำเลยเอาอวัยวะเพศของจำเลยออกจากปากของโจทก์ร่วมที่ 1 จากนั้นจำเลยใช้มือชักที่อวัยวะเพศของจำเลย จนเมื่อใกล้มีน้ำสีขาวออกมา จำเลยจึงใช้อวัยวะเพศของจำเลยมาใส่ช่องปากของโจทก์ร่วมที่ 1 ซึ่งคำเบิกความของโจทก์ร่วมที่ 1 ดังกล่าว สอดคล้องกับผลการตรวจชันสูตรบาดแผลของแพทย์ ที่ตรวจไม่พบการมีเพศสัมพันธ์ ไม่พบบาดแผลที่อวัยวะเพศภายนอก และไม่พบตัวอสุจิในช่องคลอด ประกอบกับขณะเกิดเหตุโจทก์ร่วมที่ 1 ยังเป็นเด็กมีอายุเพียง 11 ปีเศษอวัยวะเพศของจำเลยจึงยังเข้าไปในอวัยวะเพศของโจทก์ร่วมที่ 1 ไม่ได้และทำให้โจทก์ร่วมที่ 1 เจ็บ ทั้งคำเบิกความของโจทก์ร่วมที่ 1 ที่เบิกความถึงการกระทำของจำเลยสอดคล้องกับสภาพร่างกายของโจทก์ที่ 1 ในขณะนั้น คำเบิกความของโจทก์ร่วมที่ 1 จึงมีน้ำหนักให้รับฟัง ข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานของโจทก์รับฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่า จำเลยได้ใช้อวัยวะเพศของตนกระทำแก่โจทก์ร่วมที่ 1 โดยจะสอดใส่อวัยวะเพศของตนเข้าไปในอวัยวะเพศของโจทก์ร่วมที่ 1 แล้ว แต่กระทำไปไม่ตลอดเนื่องจากโจทก์ร่วมที่ 1 ยังเป็นเด็ก จำเลยจึงสอดใส่

อวัยวะเพศของจำเลยเข้าไปในอวัยวะเพศของโจทก์ร่วมที่ 1 ไม่สำเร็จ การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานพยายามกระทำชำเราโจทก์ร่วมที่ 1 แม้ต่อมาในระหว่างพิจารณาคดี ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคสอง ได้แก้ไขว่า การกระทำชำเราตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า การกระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำโดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำกระทำกับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อื่นก็ตาม แต่กฎหมายที่แก้ไขใหม่ไม่เป็นคุณแก่จำเลย จึงต้องใช้กฎหมายเดิมซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำความผิดบังคับแก่จำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 3 ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 7 วินิจฉัยมานั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น ส่วนโทษที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 7 ลงโทษจำเลยในความผิดฐานดังกล่าวมานั้นหนักเกินไป จึงเห็นสมควรลงโทษจำเลยให้เหมาะสมกับพฤติการณ์แห่งคดี

อนึ่ง ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ในส่วนแพ่งของโจทก์ร่วมที่ 1 นั้น เห็นว่า การที่ผู้ร้องซึ่งเป็นโจทก์ร่วมที่ 1 ยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 44/1 เป็นการใช้สิทธิยื่นคำร้องในคดีอาญาที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ มิใช่เป็นคดีที่ผู้เสียหายฟ้องเองโดยตรง จึงต้องถือว่าคำพิพากษาในส่วนที่โจทก์ร่วมที่ 1 เรียกค่าสินไหมทดแทนเป็นส่วนหนึ่งของคำพิพากษาในคดีส่วนอาญา ทั้งการพิพากษาคดีแพ่งที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญา ศาลจำต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีส่วนอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 46 ดังนั้น สิทธิในการอุทธรณ์ฎีกาเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนในคดีส่วนแพ่งดังกล่าวต้องถือคดีส่วนอาญาเป็นหลัก หากคดีอาญาขึ้นมาสู่การพิจารณาของศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา คดีส่วนแพ่งก็ไม่ต้องห้ามอุทธรณ์หรือฎีกา ฉะนั้น การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ในคดีส่วนแพ่งของโจทก์ร่วมที่ 1 เพราะทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นอุทธรณ์ไม่เกิน 50,000 บาท จึงเป็นการไม่ชอบ จึงให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวเสียและมีคำสั่งใหม่เป็นรับอุทธรณ์ในคดี

ส่วนแบ่งของโจทก์ร่วมที่ 1 และเมื่อสำนวนขึ้นมาสู่การพิจารณาของศาลฎีกาแล้ว ศาลฎีกาเห็นสมควรหยิบยกปัญหาดังกล่าวขึ้นวินิจฉัย โดยไม่จำเป็นต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์ภาค 7 วินิจฉัยอีก ซึ่งเมื่อพิเคราะห์ถึงพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว เห็นว่า จำนวนค่าสินไหมทดแทนที่ศาลชั้นต้นกำหนดให้แก่โจทก์ร่วมที่ 1 นั้นว่าเหมาะสมแล้ว แต่ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 7 กำหนดให้จำเลยใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ร่วมที่ 1 เป็นเงิน 60,000 บาท และแก่โจทก์ร่วมที่ 2 เป็นเงิน 20,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2548 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จนั้น เห็นว่า อัตราดอกเบี้ยผิดนัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224 ที่แก้ไขใหม่ มีผลบังคับใช้ในวันที่ 11 เมษายน 2564 จึงเห็นสมควรแก้ไขในส่วนของอัตราดอกเบี้ยให้เป็นไปตามกฎหมายที่แก้ไขใหม่

พิพากษาแก้เป็นว่า ความผิดฐานพยายามกระทำชำเราเด็กหญิงอายุยังไม่เกินสิบสามปี จำคุกกระหนงละ 4 ปี 8 เดือน รวม 2 กระหนง จำคุก 8 ปี 16 เดือน เมื่อรวมกับความผิดฐานพรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเสียจากผู้ดูแล โดยปราศจากเหตุอันสมควรเพื่อการอนาจาร จำคุกกระหนงละ 5 ปี รวม 2 กระหนง จำคุก 10 ปี แล้วเป็นจำคุก 18 ปี 16 เดือน ส่วนดอกเบี้ยของค่าสินไหมทดแทนให้จำเลยชำระในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2548 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2564 และในอัตราตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 7 (ปัจจุบันเป็นอัตราร้อยละ 3 ต่อปี) บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ 2 ต่อปี นับแต่วันที่ 11 เมษายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ร่วมทั้งสอง นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 7

(ศุภมิตร บุญประสงค์-นิรัตน์ จันทพัฒน์-สมเกียรติ ตั้งสกุล)

ศาลจังหวัดนครปฐม - นางกาญจนา ยาจิตร  
ศาลอุทธรณ์ภาค 7 - นายสัมพันธ์ บุณนาค

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |